

Lösungsvorschlag zum Fall „Zeiterfassungsprogramm“:

Die Y-GmbH (= Y) könnte gegen die X-GmbH (= X) einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 156.000,- EUR nach §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB haben.

A. Anspruch entstanden

Der **Anspruch** muss **entstanden** sein.

I. Schuldverhältnis

Dies setzt nach § 280 Abs. 1 S. 1 BGB voraus, dass zwischen den Parteien ein **Schuldverhältnis** besteht.

In Betracht kommen **vertragliche** oder **gesetzliche** Schuldverhältnisse.

1. Vertraglich

Zwischen X und Y könnte ein **vertragliches Schuldverhältnis** (§ 311 Abs. 1 BGB) in Form eines **Werkvertrages** gem. § 631 BGB zustande gekommen sein.

Zu einem **Vertragsschluss** ist es zwischen den Parteien aber **nicht gekommen**. Vielmehr nahm X zuvor Abstand von einem Vertrag über die Software mit Y.

[Anm.: Hier könnte man auch noch kurz darauf eingehen, dass ein Vertrag zwei übereinstimmende Willenserklärungen (§§ 145 ff. BGB) voraussetzt und hier zwar ein wirksames Angebot vorliegt (essentialia negotii sind gegeben), es aber an der Annahme fehlt.]

[Anm.: Ebenso kann argumentiert werden, dass das Angebot des Y nach § 146 BGB wieder erloschen ist, da X auch Wochen später keine Annahme erklärt hat und mithin die Frist aus § 147 Abs. 2 BGB abgelaufen ist.]

Ein **vertragliches Schuldverhältnis** liegt hier folglich **nicht vor**.

2. Gesetzlich

Es könnte aber ein **gesetzliches Schuldverhältnis** vorliegen.

Gem. **§ 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB** kann ein Schuldverhältnis mit Pflichten aus **§ 241 Abs. 2 BGB** durch die **Aufnahme von Vertragsverhandlungen** entstehen.

[Anm.: Es handelt sich um ein vorvertragliches (= vertragsähnliches) Schuldverhältnis, welches jedoch qua Gesetz entsteht und daher auch als „gesetzliches“ Schuldverhältnis bezeichnet wird, vgl. Emmerich, in: MüKoBGB, 8. Aufl. 2019, § 311 BGB Rn. 38]

Vertragsverhandlungen beginnen mit der **Maßnahme eines Vertragsteils, die den anderen Teil zum Abschluss** des Vertrags **veranlassen soll** und sie **enden** mit dem **Abbruch der Verhandlungen oder dem Vertragsschluss**.

Erforderlich ist, dass eine **Kommunikation zwischen den Parteien** stattfindet.

Laut Sachverhalt fanden **zwischen X und Y konkrete Verhandlungen** statt. [Ein **Angebot** seitens Y wurde ausdrücklich **übermittelt** und auch danach wurden die **Verhandlungen** mit X noch **weitergeführt**.]

Ein **gesetzliches Schuldverhältnis i.S.v. § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB** liegt vor.

[Anm.: Dies gilt zumindest bis zum Zeitpunkt, an dem X den Abbruch der Verhandlungen mit Y erklärt hat.]

II. Pflichtverletzung

Weiterhin müsste X gem. **§ 280 Abs. 1 S. 1 BGB** eine **Pflicht aus dem** benannten **Schuldverhältnis verletzt** haben.

Der Begriff der **Pflichtverletzung** bezeichnet das **objektive Zurückbleiben hinter dem Pflichtenprogramm des Schuldverhältnisses**.

[Anm.: Man könnte noch darauf eingehen, dass generell eine Verletzung von Hauptleistungs- oder Nebenpflichten in Betracht kommt.]

Vorliegend ist ein Schuldverhältnis nach § 311 Abs. 2 BGB gegeben. Aus diesem Grund kommt hier nur die Verletzung **von Rücksichtnahmepflichten im Sinne des § 241 Abs. 2 BGB** in Frage.

[Anm.: Hintergrund ist, dass mangels eines wirksamen Vertragsschlusses die primären (Haupt-) Leistungspflichten aus dem Schuldverhältnis (noch) gar nicht begründet worden sind.]

Aus jedem (auch vorvertraglichem) Schuldverhältnis folgen für die Beteiligten nach § 241 Abs. 2 BGB unterschiedliche **Schutz-, Fürsorge-, und Obhutspflichten**.

Jede Partei hat die Pflicht, **sich bei Abwicklung des Schuldverhältnisses so zu verhalten, dass die Rechte, Rechtsgüter** (Körper, Leben, Gesundheit, Eigentum, Vermögen etc.) **und Interessen des anderen Teils nicht verletzt werden**.

1. Verspäteter Verhandlungsabbruch

Aufgrund von **Aufklärungspflichten** sind Verhandlungsparteien **verpflichtet, loyal miteinander umzugehen** und **unaufgefordert über entscheidungserhebliche Umstände zu informieren, die der Gegenpartei verborgen geblieben sind**.

[Anm.: Dies gilt in gewissem Umfang selbst dann, wenn sie sich mit entgegengesetzten Interessen gegenüberstehen und deshalb legitimerweise ausschließlich auf ihren Vorteil bedacht sind.]

Vorliegend wurde **Y von X nicht darüber informiert, dass sie kein Interesse mehr an der Software hat**. Vielmehr hat X die falschen Vorstellungen der Y hinsichtlich der Abschlussbereitschaft aufrechterhalten. Dieses Verhalten stellt eine **Verletzung von Aufklärungspflichten gem. § 241 Abs. 2 BGB** dar.

[Anm.: Selbst wenn X berechtigter Weise noch nicht vollständig vom Vertrag hätte Abstand nehmen und Y über die Bestellung beim anderen Anbieter (Z) hätte informieren wollen, so wäre es zumindest zumutbar gewesen, die Vorbereitungshandlungen seitens Y zu vermeiden.]

2. Informationsweitergabe

Zudem war für X **erkennbar**, dass das **Angebotsschreiben vertrauliche Informationen enthielt**. Durch die Weitergabe der Angebotsunterlagen an den Konkurrenten Z hat X seine Schutzpflicht bezüglich des Vermögens der Y verletzt.

Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass das Angebot ein **ausdrückliches Verbot der Weitergabe** enthielt.

[Anm.: Eine Pflicht zur Geheimhaltung kann sich ebenso auf Basis einer Vereinbarung ergeben und in diesem Rahmen eine Hauptleistungspflicht darstellen. Allerdings ist dazu ein wirksamer Vertragsschluss erforderlich. Ein solcher ist nicht ersichtlich, sodass nur eine Nebenpflicht bleibt.]

Zwischenergebnis: Eine (Neben-) **Pflichtverletzung** i.S.d. § 280 Abs. 1 S. 1 BGB seitens X **liegt** hier folglich (in mehrfacher Weise) **vor**.

III. Vertretenmüssen

Gem. **§ 280 Abs. 1 BGB** müsste der Schuldner (also hier X) die **Pflichtverletzung** zu **vertreten** haben.

Nach der negativen Formulierung des **§ 280 Abs. 1 S. 2 BGB** wird das **Vertretenmüssen vermutet**. Den **Schuldner** trifft damit die **Beweislast** dafür, dass die **Verantwortlichkeit** für die Pflichtverletzung im Einzelfall (doch) **nicht vorliegt**.

Fraglich ist, ob X erfolgreich den **Entlastungsbeweis** führen kann.

Zu vertreten hat der Schuldner gem. **§ 276 Abs. 1 BGB** regelmäßig **Vorsatz** und **Fahrlässigkeit**. In Betracht kommt hier ein vorsätzliches Handeln.

[Anm.: Mit entsprechender Argumentation könnte man auch auf Fahrlässigkeit abstellen.]

Vorsätzlich handelt, wer mit **Wissen und Wollen** einen Tatbestand verwirklicht.

Vorliegend hat X **bewusst und gewollt** durch **Unterlassen der Aufklärung** Y in dem Glauben gelassen, dass die Software noch dort abgenommen werden soll, so dass die Vorbereitungshandlungen fortgeführt wurden.

Ebenso hat X **bewusst und gewollt** – trotz deutlichem Verbot aus dem gut sichtbaren Hinweis auf dem Angebot – die **Unterlagen** von Y an Z **weitergegeben**, um bei Z ein passendes Angebot zu einem besseren Preis zu erhalten.

Folglich kann X den Entlastungsbeweis nicht führen und hat die **Pflichtverletzung** zu **vertreten**.

IV. Kausaler, ersatzfähiger Schaden

Gem. § 280 Abs. 1 BGB setzt der Schadensersatzanspruch ferner einen **ersatzfähigen** und **kausal** durch die Pflichtverletzung entstandenen **Schaden** voraus.

1. Schaden

Es muss zunächst ein **Schaden entstanden** sein.

Ein Schaden ist jedes **unfreiwillige Vermögensopfer**.

Vorliegend sind Y **Vorbereitungskosten** i.H.v. 5.000,- EUR sowie Kosten für die **Angebotserstellung** i.H.v. 1.000,- EUR entstanden. Darüber hinaus ist ihm bei X ein **Gewinn** i.H.v. 50.000,- EUR **entgangen**.

Weiterhin macht Y geltend, dass **aufgrund der Weitergabe der Unterlagen Auftragsausfälle** i.H.v. 100.000,- EUR bei A und B entstanden sind.

Diese Kosten stellen ebenfalls **unfreiwillige Vermögenseinbußen** dar.

[Anm.: Im Hinblick auf die Angebotserstellungskosten kann dies fraglich sein, da dort noch nicht von einem Vertragsschluss ausgegangen werden konnte. Daher könnte man auch eine (freiwillige) Aufwendung annehmen.]

Y sind damit unterschiedliche Schadenspositionen entstanden.

2. Kausalität

Der Schaden muss **infolge der Pflichtverletzung** (= **kausal**) entstanden sein.

Die **Vorbereitungskosten** wären bei Y objektiv **nicht angefallen**, wenn X **rechtzeitig darüber informiert** hätte, dass gar kein Interesse mehr an der Lieferung durch Y besteht, mithin die **Aufklärungspflichten erfüllt** worden wären.

Ferner ist anzunehmen, dass **ohne die Weitergabe der Informationen** von X an Z, der Y der Gewinn sowohl aus dem Geschäft mit X als auch aus den Geschäften mit A und B nicht entgangen wäre.

[Anm.: Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Z ohne die Unterlagen von Y gar nicht in der Lage gewesen wäre, eine solche Software zu programmieren.]

Die **Kosten für die Angebotserstellung** wären hingegen **auch ohne die Pflichtverletzung** seitens X **entstanden** und sind damit **nicht kausal**.

[Anm.: Kausalität läge nur vor, wenn X die Abschlussbereitschaft von vornherein vorgetäuscht hätte. Dann wäre bereits in dieser Täuschung eine Pflichtverletzung zu sehen, die zu dem Schaden in Form der Angebotserstellungskosten geführt hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall.]

3. Ersatzfähigkeit

Der entstandene **Schaden** muss zudem auch **ersatzfähig** sein.

Der **Umfang des Schadensersatzes** richtet sich nach den **§§ 249 ff. BGB**.

Gemäß § 249 Abs. 1 BGB ist der **Zustand herzustellen**, der **bestünde**, wenn das **schädigende Ereignis nicht eingetreten** wäre (sog. **Naturalrestitution**).

a) Gewinn aus Geschäft mit X

Erfasst ist zum einen das **positive Interesse (Erfüllungsschaden)**. Das heißt, Y wäre so zu stellen, wie sie stünde, wenn ordnungsgemäß erfüllt worden wäre.

Laut Sachverhalt war **nur Y in der Lage**, die entsprechende **Software herzustellen**. Daher ist davon auszugehen, dass das Geschäft mit X ohne Informationsweitergabe nur mit Y und nicht mit Z abgeschlossen worden wäre.

Der **entgangene Gewinn** ist dabei explizit **über § 252 BGB ersatzfähig**.

b) Vorbereitungskosten

Fraglich ist, ob auch die Vorbereitungskosten ersatzfähig wären.

Vom Schadensersatz erfasst ist grundsätzlich auch das **negative Interesse (Vertrauensschaden)**. Danach wäre der Gläubiger so zu stellen, wie er stünde, wenn der von dem Vertrag nie gehört hätte.

Aus diesem Grund wären die **Vorbereitungskosten ebenfalls ersatzfähig**.

[Anm.: Aber Y fordert zugleich den Schaden in Form des positiven und negativen Interesses. Wenn der Vertrag aber erfüllt worden wäre, wären die Vorbereitungskosten ebenso angefallen. Sie sind daher nur ersatzfähig, wenn sie nicht bereits im Rahmen des Gewinns berücksichtigt sind.]

c) Gewinn aus den Geschäften mit A und B

Letztlich erfasst der Schadensersatzanspruch auch das **Integritätsinteresse**, welches Schäden durch **Verletzungen anderer Rechtsgüter** abdeckt.

Mit der Informationsweitergabe wurden auch die **Geschäfte von Y mit A und B** verhindert und damit ein entsprechender **Gewinn** für Y **vereitelt**.

Damit ist eine Rechtsgutverletzung am Vermögen von Y entstanden und mithin ein ersatzfähiger Schaden i.H.v. 100.000,- EUR.

Zwischenergebnis: Es ist dem Y ein **ersatzfähiger, kausaler Schaden** i.H.v. **155.000,- EUR** (bzw. 150.000,- EUR ohne Vorbereitungskosten) entstanden.

B. Anspruch (nicht) untergegangen

Anhaltspunkte für einen **Untergang** des Anspruchs **liegen hier nicht vor**.

C. Anspruch durchsetzbar

Anhaltspunkte für eine **mangelnde Durchsetzbarkeit** des Anspruchs **ergeben sich ebenfalls nicht**.

Ergebnis: Die Y hat gegen X einen Anspruch auf Schadensersatz i.H.v. 155.000,- EUR (oder 150.000,- EUR) aus §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB.

Lösungsvorschlag zum Fall „Swimmingpool“:

V könnte gegen H einen Anspruch auf Nacherfüllung in Form der Lieferung eines neuen Swimmingpools aus §§ 437 Nr. 1, 439 Abs. 1, 2. Alt. BGB haben.

A. Anspruch entstanden

Hierfür müsste der **Nacherfüllungsanspruch** wirksam entstanden sein.

I. Kaufvertrag

Um das **Kaufgewährleistungsrecht** zu eröffnen, müssten H und V einen **wirksamen Kaufvertrag** gem. § 433 BGB geschlossen haben.

Laut Sachverhalt „**kauft**“ V bei H einen Swimmingpool zum Preis von 1.000,- EUR und die **essentialia negotii** (= wesentlichen Vertragsbestandteile) sind **hinreichend bestimmt**.

Damit kann ein **wirksamer Kaufvertrag** zwischen H und V angenommen werden.

II. Sachmangel

Des Weiteren müsste ein **Sachmangel i.S.d. § 434 BGB** vorliegen.

Nach § 434 Abs. 1 BGB liegt ein Sachmangel vor, wenn die Sache nicht den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen oder den Montageanforderungen entspricht.

[Anm.: Das Gesetz formuliert in § 434 Abs. 1 BGB, wann eine Sache frei von Mängeln ist. Die Sache muss demnach sämtliche Anforderungen erfüllen. Für die Prüfung eines Mangels bedeutet das, dass ein solcher bereits vorliegt, wenn eine Anforderung nicht erfüllt ist. Aus der Formulierung des „und“ in § 434 Abs. 1 BGB wird folglich ein „oder“.]

1. Subjektive Anforderungen

Ein Mangel kann sich aus einer (negativen) Abweichung von den subjektiven Anforderungen nach § 434 Abs. 2 BGB ergeben.

Für einen Mangel aufgrund einer Abweichung von den subjektiven Anforderungen bedarf es daher zunächst einer vertraglichen Absprache (siehe **vereinbarte** Beschaffenheit, **vertraglich vorausgesetzte** Verwendung) über die Anforderungen an die Kaufsache.

Vorliegend haben die Parteien sich vertraglich über keine spezifischen Anforderungen verständigt.

Ein Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 2 BGB liegt folglich nicht vor.

[Anm.: Die subjektiven Anforderungen untergliedern sich in die vereinbarte Beschaffenheit (Nr. 1), die vertraglich vorausgesetzte Verwendung (Nr. 2) und das vereinbarte Zubehör (Nr. 3). Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass die Parteien sich hierüber verständigt haben müssen. Der Sachverhalt gibt hier keine Anhaltspunkte, dass die Parteien sich über eine dieser Anforderungen verständigt haben. Da es bereits an einer solchen (subjektiven) „Absprache“ mangelt, wurden die Prüfungspunkte hierunter zusammengezogen und ein Mangel letztlich verneint. Sofern jemand – mit entsprechender Argumentation – eine Gegenansicht vertritt, wäre eine detaillierte Prüfung unter den jeweiligen Tatbestand erforderlich.]

2. Objektive Anforderungen

Ein Sachmangel kann ferner in einer negativen Abweichung von den objektiven Anforderungen nach § 434 Abs. 3 BGB bestehen.

Ein **Sachmangel** liegt nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB vor, wenn sich der Pool **nicht** für die **gewöhnliche Verwendung eignet**. Welche Verwendung als gewöhnlich anzusehen ist, bestimmt sich durch einen **Vergleich mit Sachen derselben Art**.

Vergleichbare Sachen sind hier andere Swimmingpools, deren Verwendung darin besteht, Wasser aufzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass durch das Loch am Boden Wasser entweichen kann, sodass sich der Pool nicht für die Verwendung eignet, für die Pools gewöhnlich gebraucht werden.

Ein Sachmangel nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 BGB liegt vor.

Ferner liegt ein Sachmangel vor, wenn der Pool nicht über die übliche Beschaffenheit verfügt, § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB. Die übliche Beschaffenheit bestimmt sich einmal anhand eines **Vergleichs mit Sachen derselben Art** (§ 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2, a) BGB). Weiterhin können (qualifizierte) öffentliche Äußerungen bestimmen, welche Beschaffenheit als üblich anzusehen ist (§ 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 b) BGB). Eine öffentliche Äußerung ist hier nicht ersichtlich, weshalb sich die üblichen Beschaffenheit einzig aus einem Vergleich mit Sachen derselben Art ergibt.

Die Beschaffenheit vergleichbarer (insb. neuer) Swimmingpools ist eine unversehrte Außenwand. Der Swimmingpool hat ein Loch am Boden und entspricht demnach nicht der üblichen Beschaffenheit vergleichbarer Pools.

Ein Sachmangel nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 BGB liegt vor.

[Anm.: Anhaltspunkte für eine vorab zur Verfügung gestellte Probe oder ein Muster (Nr. 3) sowie Zubehör (Nr. 4) und einen daraus ableitbaren Mangel gibt es nicht.]

Somit liegt insgesamt ein **Sachmangel i.S.d. § 434 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 und 2 BGB** vor.

[Anm.: Zu den Anforderungen an die Mangelfreiheit gehört auch, dass die Sache den Montageanforderungen nach § 434 Abs. 4 BGB entspricht. Weiterhin liegt auch in einer Falschlieferung (§ 434 Abs. 5 BGB) ein Mangel. Der Sachverhalt gibt keine Anhaltspunkte, dass der Swimmingpool montiert werden muss bzw. dass ein Mangel in der Montage gegeben sein könnte. Auch eine Falschlieferung ist hier abwegig. Sofern einzelne Mangeltatbestände erkennbar nicht in Frage kommen, können diese entweder mit einem kurzen Verweis abgelehnt oder gänzlich weggelassen werden.]

Zwischenergebnis: Der Swimmingpool weist einen Mangel nach § 434 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 und 2 BGB auf.

III. Bei Gefahrübergang

Der **Sachmangel** müsste zudem bereits **bei Gefahrübergang** vorgelegen haben.

Der Gefahrübergang ist bei einem Kaufvertrag gem. **§ 446 S. 1 BGB** der **Zeitpunkt der Übergabe** der Kaufsache **an den Käufer**.

Der Sachverhalt enthält **keine Angaben zum Zustand** des Pools bei **Übergabe**, so dass nicht eindeutig erkennbar ist, wann der Mangel entstanden ist.

Grundsätzlich hat der **Anspruchssteller** die anspruchsbegründenden Tatsachen zu **beweisen**, sodass die Beweislast hier dem V obläge.

Es könnte jedoch die **Beweislastumkehr nach § 477 Abs. 1 S. 1 BGB** greifen.

Demnach wird bei **Sachmängeln**, die sich **innerhalb eines Jahres** nach Gefahrübergang **zeigen**, **vermutet**, dass sie zu diesem Zeitpunkt **bereits vorlagen**.

§ 477 BGB **setzt** das Vorliegen eines **Verbrauchsgüterkaufs voraus**.

[Anm.: Dies ergibt sich daraus, dass die Norm im Untertitel 3 verortet ist und die Vorschriften dieses Untertitels (nur) für den Verbrauchsgüterkauf ergänzend gelten (vgl. § 474 Abs. 2 S. 1 BGB).]

Verbrauchsgüterkäufe sind gem. **§ 474 Abs. 1 S. 1 BGB** Verträge, durch die ein **Verbraucher** von einem **Unternehmer** eine **Ware** kauft.

1. Verbraucher

Der **Käufer** (V) müsste **Verbraucher** sein.

Verbraucher ist **gem. § 13 BGB** jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Vorliegend kauft V den Swimmingpool für private Zwecke und ist damit Verbraucher i.S.d. § 13 BGB.

[Anm.: Ferner wird V im Sachverhalt auch als Verbraucher bezeichnet. Daher kann man – unter Verweis auf § 13 BGB – diese Prüfung kurzhalten.]

2. Unternehmer

Der **Verkäufer** (H) müsste **Unternehmer** sein.

Unternehmer ist gem. **§ 14 BGB** eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Vorliegend ist H in seiner Rolle als Verkäufer Händler und damit handelt er in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit, mithin als Unternehmer i.S.d. § 14 BGB.

[Anm.: Ferner wird H im Sachverhalt auch als Händler bezeichnet. Daher kann man – unter Verweis auf § 14 BGB – auch die Prüfung der Unternehmereigenschaft kurzhalten.]

3. Ware

Gegenstand des Vertrages müsste zudem der **Kauf einer Ware** sein.

Waren i.S.d. § 474 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 241a BGB sind insb. bewegliche Sachen (Sachen = körperliche Gegenstände, vgl. § 90 BGB).

Ein **Swimmingpool** ist ein **körperlicher Gegenstand**, der auch **beweglich** ist. Bei dem Kauf des Swimmingpools handelt es sich somit um den Kauf einer Ware.

Ein Verbrauchsgüterkauf **i.S.d. § 474 Abs. 1 S. 1 BGB** liegt damit vor.

Der Sachmangel, sprich das Loch im Pool, hat sich zudem **fünf Monate nach der Übergabe** und damit innerhalb von **einem Jahr** seit Gefahrübergang gezeigt.

Anhaltspunkte dafür, dass die Vermutungsregelung nach § 477 Abs. 1 S. 1 BGB ausgeschlossen ist, sind nicht ersichtlich (vgl. § 477 Abs. 1 S. 1 a.E. BGB). Zudem hat H die Vermutung auch nicht widerlegt.

[Anm.: Die Vermutungsregelung nach § 477 Abs. 1 S. 1 BGB greift nicht ein, wenn eine solche Vermutung aufgrund der Art der Ware oder des mangelhaften Zustands unvereinbar wäre. Weiterhin ist zu beachten, dass § 477 Abs. 1 BGB lediglich die Beweislast umkehrt. Es obliegt dann dem Verkäufer zu beweisen, dass ein Mangel im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht vorgelegen hat. Kann der Verkäufer diesen Beweis erbringen, widerlegt er die Vermutung und die Voraussetzung wäre nicht erfüllt.]

Die **Voraussetzungen des § 477 Abs. 1 S. 1 BGB** liegen folglich **vor** und daher wird **vermutet**, dass der **Sachmangel bereits bei Gefahrübergang** vorlag.

IV. Kein Gewährleistungsausschluss

Aus dem Sachverhalt ergeben sich weder ein **vertraglicher** Ausschluss, noch Anhaltspunkte für das Vorliegen eines **gesetzlichen** Gewährleistungsausschlusses.

[Anm.: Ein grds. denkbarer (gesetzlicher) Ausschlussgrund kann sich aus § 442 BGB ergeben. Danach sind die Gewährleistungsrechte ausgeschlossen, wenn der Käufer im Zeitpunkt des Vertragsschlusses Kenntnis von dem Mangel hatte. Sogar die grob fahrlässige Unkenntnis des Käufers kann unter weiteren Voraussetzungen ausreichend sein. Wichtig: § 442 BGB findet aber bei Verbrauchsgüterkaufverträgen (wie hier) keine Anwendung (vgl. § 475 Abs. 3 S. 2 BGB).]

V. Nacherfüllungsanspruch

Das **Kaufgewährleistungsrecht** ist damit insgesamt **eröffnet** und V kann die entsprechenden Rechte aus § 437 BGB geltend machen.

Nach **§ 439 Abs. 1 BGB** muss für einen Nacherfüllungsanspruch der Käufer dem Verkäufer sein **Nacherfüllungsverlangen erklären**.

Dabei hat der **Käufer die Wahl** zwischen der Beseitigung des Mangels (= **Nachbesserung**, Alt. 1) und der Lieferung einer mangelfreien Sache (= **Neulieferung**, Alt. 2).

V hat gegenüber H **erklärt**, er verlange einen **neuen Pool**, also Nacherfüllung durch **Neulieferung**.

*[Anm.: An dieser Stelle könnte zusätzlich erwogen werden, dass es sich bei dem Pool um eine **Gattungsschuld** handelt, weshalb eine Neulieferung unproblematisch ist. Ebenso könnte eine **Stückschuld** angenommen werden, dann müsste hier mit der h.M. argumentiert werden, dass bei vertretbaren Sachen (eine solche ist der Pool), ebenfalls eine Neulieferung als Nacherfüllung in Frage kommt.]*

Zwischenergebnis: Der Anspruch auf Neulieferung des Pools ist wirksam entstanden.

B. Anspruch (nicht) untergegangen

Anhaltspunkte für einen **Untergang** des Anspruchs **liegen nicht vor**.

C. Anspruch durchsetzbar

Der **Durchsetzbarkeit** des Anspruchs auf Neulieferung könnte jedoch eine **Einrede seitens H** entgegenstehen.

I. Einrede der Verjährung

Der **Anspruch** auf Nacherfüllung könnte **verjährt** sein, mit der Folge, dass H die **Leistung gem. § 214 Abs. 1 BGB verweigern** könnte.

Die **Verjährung** tritt gem. **§§ 438 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 BGB** in **zwei Jahren ab** dem Zeitpunkt der **Ablieferung** der Sache ein.

Der Anspruch auf Nacherfüllung wurde **fünf Monate nach Ablieferung** des Pools geltend gemacht und somit noch vor einer möglichen Verjährung.

H könnte sich daher nicht auf die Einrede der Verjährung berufen.

II. Einrede der unverhältnismäßigen Kosten

In Betracht kommt aber die **Einrede der unverhältnismäßigen Kosten gem. § 439 Abs. 4 BGB**.

Der Anspruch wäre demnach **nicht durchsetzbar**, wenn die Neulieferung mit **unverhältnismäßigen Kosten** verbunden wäre und H sich **darauf berufen** würde. Nach § 439 Abs. 4 S. 2 sind bei der Beurteilung insbesondere der Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels und die **Frage** zu berücksichtigen, **ob**

auf die **andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile** für den Käufer zurückgegriffen werden könnte.

Die **Neulieferung** würde H durch die eingeschränkte Weiterverkaufsmöglichkeit einen **Verlust von 250,- EUR** einbringen, die Nachbesserung kostet dagegen nur **50,- EUR**. Der **Wert des Pools** ist – mangels entgegenstehender Angaben – auf **Höhe des Kaufpreises** von 1.000,- EUR anzusetzen.

Fraglich ist aber vor allem, ob der **geflickte Pool** für V einen (erheblichen) **Nachteil** darstellen würde.

Vorliegend handelt es sich nur um ein kleines Loch am Boden des Pools. Es ist davon auszugehen, dass die Reparatur von außen nicht erkennbar ist und der Pool nach einer (fachgerechten) Ausbesserung auch problemlos nutzbar ist.

Damit liegt hier **kein erheblicher Nachteil** für V vor.

[Anm.: Man könnte aber auch die andere Ansicht vertreten, etwa mit der Argumentation, dass die Ausbesserung ggf. sichtbar wäre und bei einem geflickten Pool die Gefahr besteht, dass trotz Ausbesserung die Undichtigkeit weiter / wieder auftritt. Dann könnte man einen erheblichen Nachteil bejahen.]

Die Kosten einer **Neulieferung** wären aber **fünfmal so hoch** wie die einer **Reparatur** und haben **angesichts des Wertes in mangelfreiem Zustand** auch eine **erhebliche Höhe**. Daher sind die **Kosten der Neulieferung unverhältnismäßig** hoch.

H kann sich damit auf § 439 Abs. 4 BGB berufen. *[a.A. vertretbar (s.o.)]*

In der **Verweigerung der Neulieferung** liegt zudem die **erforderliche Erklärung** der Einrede. Der **Anspruch** des V auf Nacherfüllung **beschränkt sich** somit gem. **§ 439 Abs. 4 S. 3 BGB** auf **Nachbesserung**.

Ergebnis: V hat gegen H einen **Anspruch auf Nacherfüllung** aus **§ 437 Nr. 1, 439 BGB**. H kann die Neulieferung allerdings unter Verweis auf **§ 439 Abs. 4 BGB** verweigern, sodass sich der Anspruch nach **§ 439 Abs. 4 S. 3 BGB** auf die **Nachbesserung** (**§ 439 Abs. 1, 1. Alt. BGB**) beschränkt.

Antworten zum Fragenteil:

1. Was kennzeichnet ein vorvertragliches Schuldverhältnis?

- Grundsätzlich ist nach **§ 311 Abs. 1 BGB** zur **Begründung eines Schuldverhältnisses** durch Rechtsgeschäft sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ein **Vertrag** zwischen den Beteiligten **erforderlich**, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.
- Nach **§ 311 Abs. 2 BGB** kommt in bestimmten Fällen jedoch bereits vor dem Schluss eines Vertrages ein **vorvertragliches Schuldverhältnis** zustande (sog. „*culpa in contrahendo*“ oder **c.i.c.** = „Verschulden bei Vertragsschluss“).
- Im Rahmen eines solchen vorvertraglichen Schuldverhältnis entstehen mangels Vertragsschlusses **keine vertraglichen (Haupt-) Leistungspflichten**, sondern **ausschließlich Schutzpflichten i.S.d. § 241 Abs. 2 BGB**.
- Bei **Verletzung** der Schutzpflichten aus dem **vorvertraglichen Bereich** kann der Verletzer **gem. § 280 Abs. 1 BGB schadensersatzpflichtig** sein.

2. Wie kommt ein vorvertragliches Schuldverhältnis zustande?

- Gem. **§ 311 Abs. 2 BGB** kommt ein **Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 BGB** (sog. „*culpa in contrahendo*“) zustande durch:
 - die **Aufnahme von Vertragsverhandlungen** (Nr. 1);
 - die **Anbahnung eines Vertrags**, bei welcher der eine Teil im Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen gewährt oder ihm diese anvertraut, (Nr. 2) oder
 - **ähnliche geschäftliche Kontakte** (Nr. 3).

3. Was ist die sog. Sachwalterhaftung? Nennen Sie (mindestens) ein Beispiel.

- Gem. **§ 311 Abs. 3 BGB** kann ein **Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 BGB** auch **zu Personen** entstehen, die **nicht selbst Vertragspartei** werden sollen.
- Ein **solches Schuldverhältnis** entsteht insbesondere, wenn der **Dritte in besonderem Maße Vertrauen** für sich in Anspruch nimmt und dadurch **die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beeinflusst**.
- Unter S. 2 fällt die sog. **Sachwalterhaftung**. Sachwalter ist, wer wegen seiner **besonderen Sachkunde** und seiner **generellen Neutralität** generalisierend im hohen Maße (persönliches) **Vertrauen des anderen Teils in Anspruch nimmt** und dadurch die **Gewähr für eine ordnungsgemäße Durchführung**, insbesondere eines **riskanten Geschäfts** gibt.
- Beispiele für Sachwalter: Gutachter, Sachverständige, Versicherungsmakler.